

[2025년 62회 변리사 2차 시험]

新테마 특허법

-제62회 기출풀이-

안녕하세요. 박지환 변리사입니다.

금년도 변리사 2차 시험을 준비하고 치러낸 모든 수험생 여러분의 노고와 열정에 박수를 드립니다.

62회 변리사시험의 특허법 과목은 예년과 비교하여 전체적으로 '평이'한 수준이었다고 평가합니다.

각 문제별로 포인트를 살펴보면,

문제 1,2의 경우에는 최신판례를 기반으로 출제되었기에 **최신 중요 대법원 판례에 대한 철저한 대비가**,

문제 3,4의 경우에는 권리관계에 기초하여 조치 유형을 중심으로 출제되었기에 **각 유형에 대한 기본기 연습이** 중요하게 요구되었다고 보입니다.

'특허법' 과목은 우리 시험의 첫 번째 과목인 만큼, 사후적 고찰로는 시험장에서의 체감 난이도를 감히 예상하기 어려운 게 사실입니다. 사후적 평가에 너무 큰 신경을 쓰시지 않으셨으면 합니다. 이미 답안지는 우리의 손을 떠났기에 지난날에 대한 후회보다는, 그동안의 자신에 대해 격려하고 위로하는 휴식의 시간을 보내셨으면 합니다.

모두 정말 고생 많으셨습니다.

감사합니다
박지환 드림

Theme

메가변리사

박지환 변리사

[문제 - 1]: 단백질 집합체 문제

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제의 소재 - 실시권 제도

2. 전용실시권과 허락에 의한 통상실시권

- (1) 전용실시권 (제100조)
- (2) 허락에 의한 통상실시권 (제102조)
- (3) 독점적 통상실시권의 구분 (判例)

3. 권리의 '발생'

- (1) 전용실시권: **설정등록이 효력발생요건**
- (2) 독점적 통상실시권 (判例)
 - i) 특허권자가 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담 要
 - ii) 당사자 의사에 합치만으로써 발생 → 명시적 or 묵시적 可
 - (+ iii) 등록하여야만 통상실시권자 지위를 제3자 대항 可, but 독점적 권리인 점을 등록 不可)
- (3) 사안

4. 권리의 '효력'

- (1) 전용실시권: **설정행위로 정한 범위 내에서 독점·배타적 지위 有** → 특허법상 민형사상 조치 可
- (2) 독점적 통상실시권 (判例)
 - i) 설정행위로 정한 범위 내에서 실시할 권리 有 & 독점·배타적 지위 無
 - ii) 특허권자가 다른 제3자에게 통상실시권을 부여하지 않을 부작위 채무를 더 부담함
- (3) 사안

5. 권리의 '변동 등'

- (1) 전용실시권: 특허권자의 동의를 받아 이전 및 통상실시권 설정 可
- (2) 독점적 통상실시권 (判例): 특허권자의 동의를 이전 可, but 통상실시권 설정 不可
- (3) 사안

[유형: 단문형] 권리 간의 비교를 묻고 있으므로 **기본목차(발생-효력-변동 등)** 내에서 '전용실시권 vs 허락에 의한 통상실시권' 구도를 기본으로 하되, 비독점적 통상실시권과 비교하여 **독점적 통상실시권이 가지는 특수성**을 더하여 기재할 수 있습니다. (* 유사 문제: 실전GS A형 3회차 3번)

II.설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재: 丁의 행위는 이 사건 특허권 침해 ○ → 乙의 지위 검토

+ 2. 독점적 통상실시권자의 지위 (判例)

: 특허권자와 '계약'을 통해 '시장에서' 특허발명을 독점적으로 실시할 권리

3. 특허법상 손해배상청구권 (제128조 제1항)

(1) 특허법 제128조 제1항: 특허권자 or 전용실시권자 only

(2) 사안: 소극

4. 민법상 불법행위에 따른 손해배상청구권 (判例, 민법 제750조)

(1) 判例

: 제3자가 독점적 통상실시권자를 해한다는 사정을 알면서 위법한 행위를 함으로써

독점적 통상실시권자의 이익을 침해하였다면 손해배상청구 可 (∴제3자 채권침해)

(2) 사안: 제한적 적극

5. 손해배상청구권 행사 가부 - 설문(2)의 해결

i) 특허법상 손해배상청구 不可

ii) 다만, 민법상 불법행위에 따른 손해배상청구 고려 可

[유형: 법리검토형] 독점적 통상실시권자는 특허법상 손해배상청구는 행사할 수 없으나, 민법상 불법행위에 따른 손해배상청구권을 고려할 수 있습니다. 설문은 '특허법상'의 손해배상청구권에 대해서만 묻고 있으나, **배점을 고려하면** 민법상 불법행위에 따른 손해배상청구권을 기재할 필요가 있다고 생각합니다. (* 유사 문제: 실전GS A형 3회차 3번)

III.설문(3)에 대하여

1. 문제의 소재: 개별 원액 생산&수출 → ‘접합체 조성물 발명’의 ‘국내 생산’인지 문제됨
2. 속지주의 및 구성요소 완비의 원칙 (判例)
3. 국내에서의 생산으로 보는 경우 (判例)
 - 1) i) 국내에서 주요 구성을 모두 갖춘 반제품 생산 & 하나의 주체에게 수출
+ ii) 마지막 가공·조립이 극히 사소 or 간단 = 유기적으로 결합한 일체로서 작용효과 구현 可
 - 2) 단, 속지주의 & 구성요소 완비 원칙 고려하여 엄격히 판단 要
4. 직접침해 여부 - 설문(3)의 해결
 - 1): (사안포섭) 단일 주체에게 수출되어 마지막 혼합단계가 예정됨
→ ‘마지막 혼합단계 극히 사소 or 간단 & 유기적으로 결합된 일체로서의 작용효과 구현 여부’ 엄격히 판단
+ 2) 방법 청구항에 대한 침해 성립 X

IV.설문(4)에 대하여

1. 문제의 소재: 개별 원액 생산&수출 → ‘개별 원액 생산 행위’가 간접침해인지 문제됨
2. 간접침해 제도 (제127조)
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 성립요건
3. 전량 국외로 수출되는 반제품 생산 (判例)

: 최종 생산이 국외에서 일어나는 경우 → 그 전 단계의 행위에 대해서는 간접침해 X
4. 간접침해 여부 - 설문(4)의 해결
 - 1) (사안포섭) 전량 국외에서 완성품으로 혼합됨 → ‘국내 생산’으로 볼 수 있는지에 따라 구분됨
+ 2) 방법 청구항에 대한 침해 성립 X

[유형: 법리검토형] 최신판례를 기반으로 출제된 설문이며, 해당 판례는 실전GS/최종정리 강의를 통해 반복하여 연습한 주제였음은 물론, 간접침해&녹다운 수출행위와 관련된 금년도가 출제될 수 있는 마지노선이 될 수 있다고 강조한 만큼 큰 어려움 없이 풀이하셨을 것으로 기대됩니다. 戊가 어떠한 제조공정을 사용하였는지 나오지 않는 만큼 “물건” 청구항인 특허발명 기준으로 서술하시되, “방법” 청구항인 특허발명의 경우에 대해서도 결론을 간단히는 더할 수 있습니다. 직접침해 여부와 관련하여 문제에 주어진 조건이 한정적이지만, “**엄격한**” 판단을 **요한다는 판례 법리**를 사안에 녹여서 결론을 내리셨으면 충분하다고 사료됩니다. (* 유사 문제: 실전GS B2형 2회차 1번)

[문제 - 2]: 폐길화 문제

I.설문(1)에 대하여

1. 문제의 소재: 특허권의 존속기간 (제88조)
2. 허가 등에 따른 존속기간 연장등록출원 제도
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 등록요건: [필.허.기.특.공]
 - (3) 출원절차: 출원서 제출 및 시기적 제한
 - (4) 출원시 효과: 연장간주 효력

3. 이 사건 특허청의 결정

- (1) 문제점: 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분의 결합 문제
- (2) 시행령 제7조: '약효를 나타내는 활성 부분'이 새로운 물질 要
- (3) 判例
 - 1) 특허법원: 효능·효과의 정도에 차이 → '약효' 동일 X
 - 2) 대법원: i) 의약품의 효능·효과의 정도에 영향 → '약효'를 나타내는 부분 X
ii) 그 결합물 전체를 '약효를 나타내는 활성부분' X
- (4) 검토: 본 제도의 목적&취지 고려 → 오히려 악용 우려 有
- (5) 사안: (사안포섭) 허가 등에 따른 존속기간 연장대상 X → 거절이유통지 이후 거절결정이 예상됨

II.설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재: 존속기간인 연장된 특허권의 효력 검토 要
2. 허가 등에 따라 존속기간이 연장된 특허권의 효력 (제95조)

: 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건 또는 그 용도에 사용되는 물건
3. 허가 등의 대상물건의 범위 - 염변경 의약품의 경우

(+ (1) 학설: 주성분설, 유효성분설, 품목설 등)

 - (2) 判例
 - 1) 특허법원: 동일한 품목으로 취급되는지
 - 2) 대법원: i) 유효성분, 치료효과 및 용도의 동일 여부 중심 판단
ii) 염의 차이가 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 있는 정도에 불과
& [유.치.용]이 실질적으로 동일 → 존속기간이 연장된 특허권의 효력
 - (3) 검토: 제도의 취지 및 法95 명문 고려
4. 이 사건의 특허권의 효력이 미치는지: (사안포섭) 적극

[유형: 단문+법리검토형]

설문(1)의 경우에는 실전gs A형과 모의고사에서 “존속기간 연장등록 출원제도”를 다루었기에 낯설음이 덜하지 않았을까 기대하며, 직접 제시된 두 논점에 대해 적절한 분량조절이 요구됩니다. 최신판례를 기반으로 출제되었기에 해당 판례에 대한 충분한 기재가 이루어져야 할 것입니다. (* 유사 문제: 실전GS A형 5회차 2번)

설문(2)의 경우에도 염변경 의약품과 관련된 리딩케이스라고 할 수 있는 대법원 판례를 기반으로 출제된 것으로 판단되기에, 해당 판례를 중심으로 풍부한 서술이 이루어져야 합니다. (* 유사 문제: 실전GS B2형 1회차 1번)

[문제 - 3]: 발명 X 문제

I. 설문(1)의 소설문1)에 대하여

1. 문제의 소재: 명문의 규정이 없는 일부출원 취하서의 취급이 문제됨
2. 일부 출원 취하서의 취급
 - (1) 判例: i) 원칙적 불허, ii) 삭제 보정서로 선택 可 (∵ 보정과 같은 목적을 달성하기 위한 것)
 - (2) 사안: 청구항 2를 삭제하는 보정서로 선택 可
3. 기간 경과 후 제출된 보정서의 취급
 - (1) 判例: 보정 기간을 경과한 후에 제출된 출원 취하서는 반려함
 - (2) 사안: 기간이 경과하여 제출된 서류는 반려대상임
4. 특허청장 처분의 적법성 - 소설문1)의 해결: 적법

I. 설문(1)의 소설문2)에 대하여

1. 문제의 소재: 거절결정받은 출원인의 조치
2. 이견 출원에 대한 조치
 - (1) 재심사 청구 (제67조의2): 청구항 2 삭제 or 한정 '보정' 수반
 - (2) 거절결정불복심판 청구 (제132조의17): 보정 없이 청구항 2에 대한 거절결정 이유를 다툼
3. 별건 출원을 통한 조치
 - (1) 분할출원 (제52조): 청구항 2 발명에 대한 별도의 권리화
 - (+ [기타 조치] (2) 분리출원 (제52조의2) 등: 심판기각 이후 등록가능한 발명의 권리화)

[유형: 법리검토형+조치형]

소설문 1)의 경우에는 수험계에서 중요하게 다뤄지는 판례는 아니지만, 당황하지만 않았다면 기본서 내용을 바탕으로 판례법리를 서술할 수 있습니다.

소설문 2)의 경우에는 '거절결정'을 받은 출원인이 취할 수 있는 조치를 묻는 전형적인 유형에 일부 청구항에 대해서만 거절이유가 지적된 상황이 설계되었습니다. 메인으로 재심사 OR 거절결정불복심판 청구를 선택적으로 활용하는 조치를 고려하고, 그 외에도 분할출원을 함께 더 고려할 수 있습니다.

II.설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재: 출원일체의 원칙

2. 거절결정불복심판 (제132조의 17)

(1) 의의 및 취지

(2) 의견서제출기회 부여(제63조 준용): 거절결정의 이유와 '다른' 거절이유인 경우에 한정

3. 기각심결의 이유와 거절결정의 이유와의 관계

(1) 판단 (判例): '주된 취지' 부합 여부 → 다른 거절이유인지 판단

(2) 사안: (사안포섭) 청구항 3 내지 5의 기각심결 이유는 거절결정의 이유에 포함됨

→ 주된 취지 부합(∴ 출원인의 절차적 권리 보장)

4. 특허심판원 심결의 적법성 - 설문(2)의 해결: 적법

[유형: 법리검토형]

기각심결의 이유가 일부 청구항에 대한 거절이유를 근거로 하므로 전제되는 법리로 **출원일체의 원칙**을 간단히 서술한 이후, 거절결정불복심판의 심리 '**절차**'와 관련된 법리 관련 '**절차적 위법 여부**'를 중심으로 기재하였습니다. 출원인 절차권 보장에 흠결이 없다는 점을 중심으로 사안을 포섭하시면 적절할 것으로 사료됩니다. (* 유사 문제: 실전GS A형 1회차 3번)

Ⅲ.설문(3)에 대하여

1. 문제의 소재: 타 공유자의 동의 없는 실시허락에 대한 조치를 검토함

2. 공유 특허권자 甲, 乙의 지위

- (1) 자유실시 (제99조 제3항)
- (2) 실시권 설정의 제한 (제99조 제4항)
- (3) 배타적 지위 (判例): 공유자 1인이 침해금지청구 등 可
- (4) 사안: i) 별다른 약정 없는한 甲은 자유실시 可, ii) 다만 제3자에게 실시권 설정은 乙의 동의 要
→ 乙은 타인의 무단실시에 대해서는 침해금지청구 등 可

3. A사의 지위

- (1) 실시권자의 지위: 소극
- (2) 기관대행설: [계.감.전] → 甲의 실시임을 주장 可
- (3) 사안
 - 1) 다른 특별한 사정 無: 甲의 의뢰를 받아 생산·납품한 A사의 발명 X 생산행위는 甲의 실시로 취급됨
 - 2) A사가 甲의 감독을 받지 않는 등의 사정 有: A사의 발명 X 생산행위는 A사의 실시로 취급됨

4. 乙이 취할 수 있는 조치 - 설문(3)의 해결

- (1) A사의 실시행위에 대한 조치 (判例)
 - 1) (기관대행 성립시) 조치 不可
 - 2) (기관대행 불성립시) 특허침해에 기초한 민·형사상 조치
- (2) 甲에 대한 조치 - 공유물분할청구 (判例)
 - : 공유관계를 해소하고자 하는 경우에 공유물분할청구 고려 可

[유형: 조치형]

큰 배점으로 인해 현장에서 느끼는 당혹감이 컸을 것으로 예상됩니다. ‘권리관계’와 관련된 ‘조치형’ 문제에 대해서 **당사자의 지위를 검토한 이후에 이를 기반으로 다각적인 조치를 검토하는** 답안작성법을 충분히 연습하셨다면, 목차를 잡고 분량을 채워나가는 것은 크게 어렵지는 않으셨으리라 생각됩니다(# 특허권 관련: 당사자 지위 → 침해여부 → 조치). 다만, 문제에 주어진 상황에서 요구되는 조치가 선명하게 파악되지 않으므로, 실제 현장에서 체감하는 난이도는 매우 높았을 것으로 평가합니다. (* 유사 문제: 실전GS A형 5회차 4번)

[문제 - 4]: 천연물 X 문제

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제의 소재

2. 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속 주체 (제33조 제1항)

3. 발명 Y에 대한 甲,乙,丙의 지위

(1) 공동발명자 (제33조 제2항)

(2) '공동발명'의 성립요건 (判例)

1) 판단기준: [발.완.실.상.협]&[기.창.실.기]

2) 발명자란의 기재와는 별개로 실질적 판단 要

(3) 사안

1) (사안포섭) 발명자란 기재와 무관 → ① 甲은 공동발명자 X, ② 乙,丙이 공동발명자 O

2) 乙,丙에 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 귀속 (공유)

4. 발명 Y에 대한 A사의 지위

(1) 지분양도의 제한 (제37조 제3항)

(2) 사안: A사는 발명 Y의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인 X (∵ 乙의 동의 無) → 무권리자

5. 乙이 A사에 대해 취할 수 있는 조치

(1) 출원인 명의변경신청: 협의 성립시

(2) 출원인 명의변경 청구 거부: 명문 규정 無 (논의 有) → 고려 可

(+ (3) 기타: 출원인 명의변경 이후 발명자 정정)

6. 乙이 특허출원에 대해 취할 수 있는 조치

(1) A사 특허출원의 거절이유: 제33조 제1항 위반

(2) 심사청구(제59조) 및 정보제공(제63조의2): 등록배제 조치

(+ (3) 정당한 권리자 출원 (제34조) 등: 별도 출원을 통한 권리화 방안)

[유형: 조치형]

문제 3의 설문(3)과 마찬가지로 큰 배점의 조치형 문제로 체감 난이도가 높았을 것으로 사료됩니다. 마찬가지로 '권리관계'와 관련된 '조치형' 문제에 대해서 **당사자의 지위를 검토한** 이후에 이를 기반으로 **다각적인 조치를 검토**하는 방식으로 기재하였습니다(# 특박권 관련: 당사자 지위 → 권리화 조치) (* 유사 문제: 실전GS A형 5회차 4번). 출원서의 발명자 기재는 단순 명예권에 지나지 않으므로 '발명자'란의 기재와 상관없이 진정한 발명자가 누구인지를 살피어 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속주체(정당한 권리자/무권리자)를 검토한 이후에 무권리자와 그 출원에 대해 정당한 권리자가 취할 수 있는 조치를 기재하는 방식으로 서술하였습니다.

II.설문(2)에 대하여

1. 신규성 (제29조 제1항 각호) - 문제되는 특허요건

2. 특허무효심판의 청구인 적격

(1) 이해관계인 또는 심사관

(2) 사안

3. 실시권자 B사의 이해관계 인정여부

(1) 判例

1) (종래 판례) 이해관계 부정&긍정 판시 공존

2) (전합 판례) i) 제조·판매하거나 할 사람 포함, ii) 실시권자의 이해관계 소멸 X

(2) 검토

(3) 사안: (사안포섭) 이해관계 긍정

4. B사가 특허심판원에 취할 수 있는 조치 - 설문(2)의 해결: 특허무효심판 청구

[유형: 법리검토형]

전통적으로 중요하게 다뤄지고 있는 쟁점이 다시금 출제되었고, 제시된 사실관계나 설문에서 논점을 어렵지 않게 추출하여 풀이하셨을 것으로 기대합니다. (* 유사 문제: 실전GS A형 7회차 3번)